

1500583-45.2021.8.26.0366

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Latrocínio

Magistrado: ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 19/07/2022

... foi presa enquanto praticava o crime de tráfico de drogas. MARCOS se apresentou espontaneamente da Delegacia uma semana após a prisão de GABRIELLY. As imagens foram obtidas pelo sistema de investigação da Polícia Civil. No momento da ação delituosa quem estava com a arma de fogo era RYAN. RYAN fez a primeira abordagem junto à vítima do sexo masculino enquanto fechava o portão da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

1ª Vara

Avenida São Paulo, 300, Mongaguá (SP) - cep 11730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500583-45.2021.8.26.0366 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500583-45.2021.8.26.0366

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Latrocínio

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

02 DESCONHECIDOS e outros

Réu Preso

Juiz Substituto: Dr. ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Relatório

Cuida-se de ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra MARCOS HENRIQUE GUIMARÃES CARVALHO e GABRIELLY DA SILVA, imputando-lhes a prática do crime tipificado no artigo 157, parágrafo 3º, inciso II, do Código Penal, na forma tentada (artigo 14, inciso II, do Código Penal).

Sustenta a denúncia que, em 27 de junho de 2021, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios, MARCOS e RYAN DE FRANÇA SILVA AGUIAR tentaram subtrair, para proveito comum, o automóvel da marca/modelo Ford Ranger, placa GDW9877, ano 2017, pertencente às vítimas José e Maria. sendo certo que, da violência empregada, somente não resultou o óbito da vítima José por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Consta ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, GABRIELLY, concorreu, prestando auxílio material, para a prática do delito acima descrito.

Narra que na data dos fatos, previamente decididos a praticar o roubo, os criminosos se dirigiram até o local dos fatos, que funciona como casa de veraneio das vítimas. Para tanto, ajustaram que GABRIELLY, namorada de RYAN, monitorasse a movimentação dos ofendidos. Em dado momento, GABRIELLY notou que o casal de idosos estava prestes a sair da residência, vez que a vítima José trancava o portão enquanto sua esposa, Maria, esperava no automóvel. Nesse instante, a denunciada sinalizou aos demais criminosos que vieram de encontro à José, anunciando o roubo. De imediato, MARCOS e RYAN imobilizaram a vítima José, aplicando um golpe popularmente chamado de "gravata", sendo que um deles passou a dar coronhadas com

um cabo de arma no ofendido, determinando que ele entregasse a chave do automóvel. A vítima Maria, notando as agressões a seu esposo, saiu do carro, indo em direção à via pública, onde passou a gritar por socorro. Não tendo encontrado a chave do automóvel, o denunciado RYAN desferiu um tiro na região do abdômen de José, bem como na região do joelho de Maria. Em contínuo, os criminosos fugiram do local. A morte de José somente não se consumou pois foi socorrido a tempo.

A prisão preventiva de GABRIELLY foi decretada em 12 de setembro de 2021 (fls. 86 do apenso nº 1500273-14.2021).

A denúncia foi recebida em 16 de setembro de 2021, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva dos réus MARCOS e RYAN (fls. 201/203).

Os réus GABRIELLY e MARCOS foram citados (fls. 252 e 254) e apresentaram resposta a acusação (fls. 305/308 e 219/222).

Em audiência (fls. 372/373) foi determinado o desmembramento do feito em relação à RYAN em razão de sua não localização e foram ouvidas as vítimas e testemunhas, e ao final os réus foram interrogados; MARCOS confessou a subtração patrimonial, mas disse que não tinha intenção de atirar em ninguém, e GABRIELLY negou qualquer envolvimento no crime, estando nas proximidades do local visitando parentes de RYAN.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia (fls. 451/459). A Defesa de GABRIELLY alegou (fls. 466/468) a inexistência de provas, participação de menor importância ou o reconhecimento da confissão. Por sua vez, a Defesa de MARCOS pugnou pela absolvição e alegou o cerceamento de defesa (fls. 477/486).

Folhas de antecedentes e certidões de distribuição criminal a fls. 487/499.

Fundamentação

A despeito de compreensão diversa sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento, na Súmula 603, segundo o qual “a competência para o processo e julgamento de latrocínio é do Juiz singular e não do Tribunal do Júri”. Tem-se, então, precedente vinculante a ser observado.

Preliminar

Não há cerceamento de defesa ou qualquer nulidade a reconhecer quanto às imagens da câmera de segurança. A decisão tomada na audiência de fls. 372/373 determinou a vinda aos autos das gravações e do laudo respectivo, o que veio a fls. 445/446 e 374/408, respectivamente, antes da intimação das partes para oferecerem as alegações finais escritas.

Existência e Autoria

A existência e a autoria da ação criminosa restaram parcialmente demonstradas pelas provas pericial, documental e oral produzidas.

Com efeito, as declarações das vítimas são uníssonas no sentido de que foram surpreendidas na saída do portão de sua residência por ao menos dois indivíduos, um deles armado, que anunciaram o assalto e pretendiam subtrair o carro que retiravam da garagem, tendo disparado contra Maria que pedia socorro e, depois, não encontrada a chave do veículo, também contra José, antes de se evadirem.

José disse que, por volta das 13h30 e 14h00, ele e sua esposa já estavam prontos para irem para Itatiba. O carro já estava do lado de fora. No momento em que o ofendido estava colocando o último cadeado no portão ouviu uma pessoa vindo por trás, dizendo que era um assalto, ordenando que a vítima entregasse a chave do carro. Quando conseguiu se desvencilhar do assaltante, a vítima percebeu que sua esposa havia saído do carro, momento em que presenciou que um dos criminosos lhe desferiu um tiro na perna. Como ficou muito assustado a vítima não conseguiu encontrar, de pronto, a chave do veículo, razão pela qual um dos assaltantes passou a lhe desferir coronhadas na cabeça. Os golpes ocasionaram sangramento. Em dado momento, os criminosos adentraram no interior do veículo, e quando perceberam que chave não estava no contato do carro, retornaram em direção à vítima (José) disparando um tiro contra o ofendido e, posteriormente, fugiram do local. José reuniu as suas forças e conseguiu retomar a direção do veículo, quando foi em direção ao Pronto Socorro. Segundo informações médicas, o tiro recebido por sua esposa entrou e saiu da perna. A vítima depoente (José) foi encaminhada ao Hospital de Itanhaém, onde foi submetido a procedimento cirúrgico na região da barriga. Após

três dias o ofendido recebeu alta. A vítima não viu, mas acredita que um dos criminosos subtraiu o celular. O ofendido chegou a ver dois criminosos, um que estava com a arma e outro que estava agitado e gritando "atira! Atira". Reconheceu MARCOS como o assaltante que estava com a arma de fogo e desferiu os disparos. Posteriormente, viu pelas filmagens, a presença de uma mulher. O depoente viu as filmagens. Reafirmou que o indivíduo que estava com a sacola foi quem atirou. Quando efetuou o reconhecimento em solo policial, somente estava presente o réu que na ocasião do delito estava vestindo uma camisa listrada.

Maria disse que, no momento do ocorrido, ela e seu marido estavam se arrumando para voltarem para casa. Como sempre, entrou dentro do carro levando consigo os cachorros, enquanto seu marido fechou o último cadeado do portão. Em dado momento, viu que um indivíduo estava com o braço no pescoço de seu marido. Em razão disso, saiu do carro e começou a gritar por socorro, quando então recebeu um tiro na perna. Pode então perceber que seu marido estava todo ensanguentado, razão pela qual continuou a pedir socorro. Reconheceu MARCOS como o indivíduo "moreninho" que estava com a sacola na mão e que estava segurando seu marido. Na delegacia reconheceu o rapaz apresentado, porém não era o atirador, mas o outro comparsa. As testemunhas ouvidas confirmam a dinâmica de preparação da empreitada criminosa e mesmo de seu desenvolvimento, inclusive posterior com a fuga dos indivíduos.

A testemunha Tibúrcio disse que atendeu os assaltantes em seu estabelecimento. Eram três pessoas, dois rapazes e uma moça. Eles consumiram em seu estabelecimento. Não viu o ocorrido, mas ouviu os disparos. Seu estabelecimento é próximo à casa da vítima. Os disparos ocorreram pouco depois que eles saíram de seu estabelecimento. Não sabe precisar o horário que eles estavam no estabelecimento, mas foi na parte da tarde. Viu os dois rapazes correndo e a moça pegando um Uber. O rapaz "branquinho" correu na frente e o "moreno" correu atrás. Se recorda de ter visto uma pipa na mão do "branquinho". Ele estava simulando que estava empinando uma pipa. A pipa não estava no ar. Reconheceu GABRIELLY e MARCOS, o qual identificou como o rapaz "moreninho".

A testemunha Gilson disse ser motorista de aplicativo Uber. Soube dos fatos após de três ou quatro dias. Disse que foi levar um casal e mais um rapaz de São Bernardo e depois combinou fazer a volta particular. Deixou os passageiros no local e, depois do almoço, conectou o aplicativo, momento em que apareceu uma solicitação de corrida solicitada por uma pessoa chamada "Andrea". Faltando cerca de 500 metros para completar a corrida, quando ela mandou a mensagem que o depoente havia passado do local. Após pedido da moça, o depoente retornou. Ao chegar ao local verificou que a moça estava desesperada, pois veio correndo ao seu encontro. Durante a corrida a moça ficou agachada. Já no início da viagem, conseguiu visualizar um rapaz moreno alto correndo, e dois carros atrás deles. Atrás desse rapaz havia dois carros, dois homens dentro de um carro e em outro um senhor com uma mulher. A passageira pedia para que ele "saísse fora", pois caso contrário poderia tomar um tiro. Soube posteriormente da conduta criminosa. Em juízo reconheceu GABRIELLY que se apresentou por Andrea.

Finalmente, o policial militar Ricardo atestou que foi informado via COPOM da ocorrência de que um casal havia sido alvejado. Foi apurado através de uma testemunha que as vítimas haviam se deslocados por meios próprios até o Pronto Socorro de Vera Cruz. Ao chegarem no estabelecimento médico, os policiais verificaram que as vítimas foram de fato alvejadas. Ainda, se apurou que o senhor quando fechava o portão, foi abordado por um indivíduo. A senhora, vendo que seu marido estava sendo agredido, passou a gritar por socorro, quando assim foi alvejada na perna. Em dado momento, outro criminoso entrou em luta corporal com a vítima do sexo masculino. Os fatos foram comunicados à Autoridade Policial. Ouviu a versão das vítimas enquanto elas estavam no pronto socorro.

Tais depoimentos são corroborados, primeiro, pelo prontuário médico (fls. 76/86) e pelo laudo do exame de corpo de delito (fls. 358/359 e 360/361), que constatou que José apresentava "cicatriz de ferimento perfurocontundente na região da fossa ilíaca direita do abdome. Cicatriz de ferida incisa na linha média do abdome" e concluiu se tratar de "lesões corporais de natureza GRAVE pelo perigo de vida ocasionado pelas lesões internas que necessitaram pronta intervenção cirúrgica"; e

que Maria apresentava “duas cicatrizes de ferimentos perfurocontusos na coxa esquerda” e concluiu se tratar de “lesões corporais de natureza GRAVE pela incapacidade para atividades habituais por mais de 30 dias”. E, depois, pelas imagens das câmeras de segurança da via pública (fls. 174/184, 374/408 e 445/446), que retratam dois homens e uma mulher sentando-se em cadeiras na calçada, observando a movimentação da rua; a mulher caminhando sozinha em direção a uma das ruas próximas; os três indivíduos caminhando na rua em direção à rua da residência das vítimas, com a mulher carregando uma lata nas mãos; um dos homens abordando o casal e, depois, vindo em reforço o segundo dos homens, aparentemente anunciando o assaltado, realizando agressões e ingressando no veículo das vítimas e, depois, os disparos de arma de fogo; e, por fim, os dois homens correndo em via pública.

Os depoimentos do policial civil e do delegado de polícia esclarecem em que termos e forma obtidos estes elementos probatórios e realizada a identificação dos acusados.

Roberto disse que tomou ciência de uma tentativa de roubo de um casal de senhores em Mongaguá. Também foi informado que as vítimas foram alvejadas pelos criminosos. Em razão disso, o depoente, juntamente com outro policial, diligenciou até o local dos fatos. Chegando lá, conseguiram obter imagens de câmeras de segurança de uma residência próxima. Nas gravações era possível ver que antes das vítimas saírem com a caminhonete, a dupla de rapazes juntamente com uma moça, passaram pela residência em que as vítimas estavam ao menos por duas vezes, oportunidade em que fitaram os olhos para dentro do imóvel. Após, ficaram em um bar próximo na esquina, e atravessando a rua ficaram em sombra consumindo o que compraram. Quando perceberam que as vítimas saíram da casa com a caminhonete, a dupla de homens veio na direção dos senhores. Rapidamente a mulher correu para uma paralela que estava ao lado. A senhora passou a gritar, quando foi alvejada. Também visualizaram que um dos criminosos dava uma coronhada no senhor, que em dado momento foi alvejado. Após disparar contra a vítima, os assaltantes se evadiram correndo em direção a uma rua lateral sentido pista. Em outras imagens, verificaram que um carro foi atrás dos rapazes que iam correndo. Também conseguiram obter que GABRIELLY havia tomado uma corrida por aplicativo. Após as investigações, conseguiram localizar a ré, que admitiu informalmente que estava com seu amásio de nome RYAN juntamente com MARCOS, que pretendiam fazer uma “fita” em Mongaguá. Os policiais conseguiram obter mandado de prisão em face de MARCOS e RYAN. MARCOS, em dado momento da filmagem, aparece segurando uma sacola. Quando ouvido na Delegacia, admitiu que estava com uma sacola em que estava a arma e cordas e fitas para amarrar a vítima. No momento da abordagem das vítimas a arma estava com RYAN. MARCOS chegou a adentrar no veículo das vítimas. Na primeira vez que passaram pela casa da vítima MARCOS passou segurando uma pipa. GABRIELLY passou juntamente com os rapazes pela casa da vítima algumas vezes. Também soube, em contato a vítima Maria, que um dia antes GABRIELLY havia batido em sua porta, e pedido um copo de água e um dinheiro, dizendo que precisava para visitar a mãe, que estava doente em uma cidade do interior. Luiz Carlos disse que durante as investigações foram colhidas imagens de câmeras de segurança, onde foi verificado o envolvimento de três pessoas, dois rapazes e uma moça. As diligências permitiram identificar e qualificar as pessoas. Inclusive foi realizada diligência em São Bernardo do Campo para a oitiva de um motorista de aplicativo que atendeu a referida moça. O referido motorista conseguiu efetuar o reconhecimento de uma moça e de outro rapaz. Em razão dos fatos, efetuou uma representação pela prisão preventiva dos envolvidos. GABRIELLY foi presa enquanto praticava o crime de tráfico de drogas. MARCOS se apresentou espontaneamente da Delegacia uma semana após a prisão de GABRIELLY. As imagens foram obtidas pelo sistema de investigação da Polícia Civil. No momento da ação delituosa quem estava com a arma de fogo era RYAN. RYAN fez a primeira abordagem junto à vítima do sexo masculino enquanto fechava o portão da casa, quando em posse da arma de fogo desferiu coronhadas contra a vítima. RYAN também desferiu um tiro conta barriga da vítima José. Na sequência, MARCOS adentrou ao veículo, quando assim passou a fazer a exigência das chaves para a esposa de José. Como a vítima conseguiu sair do carro, foi alvejada por um disparo de arma de fogo. Não ficou claro que MARCOS

tenha empurrado RYAN, ou que ele tivesse a intenção de impedir que RYAN dessa continuidade no delito. MARCOS se aproximou de RYAN, mas não sabe qual teria sido o conteúdo da conversa. Em pelo menos um momento MARCOS aparece com uma pipa. Não se recorda de imagens dos dias anteriores. Quanto à participação de GABRIELLY, disse que a acusada mencionou ter sido informada pelos rapazes que eles fariam uma “fita” em Mongaguá. Em dado momento, a acusada junto com os rapazes passou a monitorar a vítima por alguns minutos, a fim de praticar a subtração. GABRIELLY teria sido orientada por seus comparsas a chamar um aplicativo. Após os fatos GABRIELLY recebeu um contato via facebook de RYAN solicitando auxílio para voltar para Praia Grande.

Tudo o que se soma à confissão judicial de MARCOS (artigo 197 do Código de Processo Penal), ainda que parcial.

Conquanto MARCOS tenha confessado a sua participação na subtração patrimonial, defende não ter anuído aos disparos de arma de fogo.

Nos moldes do artigo 29 do Código Penal, todo aquele que concorre para a conduta criminosa, autor, coautor ou partícipe, indistintamente, responde pelo crime, na medida de sua culpabilidade. Além disso, reserva a lei desde logo uma causa de diminuição de pena à participação de menor importância (parágrafo 1º) e uma causa de aumento de pena à cooperação dolosamente distinta, daquele que não adere ao resultado mais grave, mas que lhe era previsível (parágrafo 2º).

Resta a analisar o exato desígnio que norteou a participação do agente na ação criminosa. E como se sabe, “o dolo é a vontade consciente de realizar um crime ou – mais tecnicamente – a vontade consciente de realizar o tipo objetivo de um crime, também definível como saber e querer em relação às circunstâncias de fato do tipo legal. Assim, o dolo é composto de um elemento intelectual (consciência, ou representação psíquica) e de um elemento volitivo (vontade, ou energia psíquica), como fatores formadores da ação típica dolosa” (Juarez Cirino dos Santos, Direito Penal – Parte Geral, 5ª ed., 2012, p. 126). É dizer, o dolo se caracteriza no estágio meramente subjetivo (interno, psíquico) do comportamento humano. Por isto, a sua aferição se faz a partir das circunstâncias que cercam a conduta do agente, do contexto externo de seu comportamento, assim a partir da prova indiciária de que trata o artigo 239 do Código de Processo Penal.

No caso, MARCOS confessadamente acertou com RYAN a prática do roubo naquele local e contra aquelas vítimas e transportava a sacola em que sabidamente estava a arma de fogo municionada, momentos antes de entregá-la a RYAN, que a empregou no roubo e efetuou disparos. É inequívoca, por isto, a adesão à prática da subtração patrimonial mediante o emprego de violência ou grave ameaça com arma de fogo.

Contudo, os elementos probatórios produzidos não comprovam tenha MARCOS efetivamente contribuído para a realização de disparo voltado à morte das vítimas, assim desejado ou assumido o risco de que se produzisse tal resultado. A despeito do relato de José de que RYAN teria gritado “atira, atira!”, não se extrai de seu depoimento elementos seguros sobre a exata dinâmica da atuação de cada um dos agentes, havendo alguma confusão entre o que um ou outro dos agentes teria realizado, sobretudo diante do que se extrai das imagens das câmeras de segurança e o que se justifica diante dos momentos de tensão vividos. Certo que RYAN falava alguma coisa, inclusive como disse Maria, mas que não se recordava exatamente do conteúdo. Extrai-se da imagem que MARCOS efetivamente se pôs diante de RYAN, com a arma em punho, e de José, dá-lhe um empurrão e sai correndo. Em seguida, RYAN realiza o disparo, apanha o celular da vítima e sai em fuga. Assim, não se pode extrair com segurança a conclusão de que MARCOS tenha admitido a realização de disparos letais às vítimas, agindo assim com animus necandi.

Quanto a GABRIELLY, sua participação também restou demonstrada, ainda que de menor importância. De seu próprio interrogatório se colhe o pleno conhecimento da intenção de RYAN e MARCOS realizar o roubo. Como se viu, o depoimento das testemunhas e as imagens das câmeras de segurança atestam que ela estava junto com MARCOS e RYAN, então já portando a arma de fogo e momentos antes da subtração.

Viajou, portanto, para Mongaguá, sendo de todo incrível a versão da autodefesa que iam visitar uma tia, nunca ouvida, menos ainda deixando filho em casa. Durante a ação da dupla de homens, pediu uma corrida de transporte por aplicativo para

empreender a fuga e, não tendo logrado embarcar RYAN, posteriormente providenciou outro transporte para o retorno de RYAN à Praia Grande.

Tem-se, então, que prestado auxílio à empreitada criminosa, ainda que limitada ao encorajamento, vigia e organização da fuga. E não se reconhece participação mais ampla, inclusive com a seleção das vítimas e coleta de informações sobre sua rotina à míngua de elementos probatórios produzidos em contraditório, pois a notícia dos agentes policiais de que Maria teria sido abordada em casa por GABRIELLY, simulando um pedido de ajuda, não veio corroborada pelo efetivo depoimento da vítima neste sentido. Nada a propósito foi perguntado a Maria.

Ainda, não há prova segura de adesão de GABRIELLY ao animus necandi com que agiu RYAN. Neste sentido, as circunstâncias da atuação de MARCOS são indícios de que o trio não combinou nem previu como resultado possível e indiferente o resultado morte das vítimas, a despeito do emprego da arma de fogo municada. Tem-se, então, adesão limitada à ofensa à integridade física das vítimas.

Enfim, nestes termos, restaram parcialmente confirmadas as teses de fato da acusação e “não há elementos de prova que tornem viável ter ocorrido fato concreto diverso de qualquer proposição fática que integre a imputação.” (Gustavo Badaró, Epistemologia Judiciária e Prova Penal, RT, 2019, p. 259).

Adequação Típica

Prevista na lei penal, a conduta dos acusados também é materialmente típica, pois causa expressiva lesão, ainda que potencial, ao bem jurídico penalmente protegido. Por consequência, a severa intervenção penal não viola o direito constitucional à liberdade, atendido o postulado da proporcionalidade.

Como se disse, o quadro probatório evidenciou que os acusados praticaram, de forma consciente e deliberada, a conduta de tentar subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça e efetiva violência, exercida com arma de fogo, mas fugiu da unidade de designios com que ajustaram a prática criminosa a realização dos disparos em condições que colocaram em risco a vida das vítimas, como se disse.

Daí porque acolho em parte a pretensão acusatória para, na forma do artigo 29, parágrafo 2º, do Código Penal, reconhecer a prática do crime do artigo 157, caput, do Código Penal, com a incidência das causas de aumento do parágrafo 2º, inciso I, e do parágrafo 2º-A, inciso I, do mesmo dispositivo.

Ainda assim, tal resultado da ação criminosa, e com efetiva ocorrência de lesão corporal de natureza grave, lhes era previsível, por todo o contexto da prática delitiva, com arma de fogo municada, razão de se aplicar a causa de aumento da parte final do artigo 29, parágrafo 2º, do Código Penal.

Reconhece-se, como já se apontou, a participação de menor importância de GABRIELLY, aplicando-se a causa de diminuição do artigo 29, parágrafo 1º, do Código Penal.

De outra parte, conforme comprovado pela qualificação em sede policial e em juízo das vítimas, elas eram maiores de 60 anos, de resto como é perceptível a qualquer pessoa, portanto bem cientes os acusados desta condição pessoal, aplicando-se a agravante do artigo 61, inciso II, alínea 'h', do Código Penal.

Não incide a agravante da reincidência diante das certidões de fls. 489 e 494/499, diante da primariedade de MARCOS e observado que a condenação transitada em julgado de GABRIELLY, pela prática do crime do art. 168, § 1º, III, do CP (0039299-43.2014.8.26.0050), teve a pena extinta pouco mais de cinco anos antes do cometimento do delito ora em julgamento, após o transcurso do lapso depurador.

Ilicitude e Culpabilidade

Presente a tipicidade, não há elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que a conduta tenha sido praticada em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou em exercício regular de direito, o que excluiria a ilicitude da conduta, de acordo com o artigo 23 do Código Penal.

À época dos fatos, os réus eram maiores de 18 anos, atendido o critério constitucional de imputabilidade (artigo 228 da Constituição Federal); e eram plenamente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento, sem que haja elementos a indicar ou a criar séria dúvida de não tivessem plena saúde mental, estivessem fortuitamente embriagados ou sob o efeito de substância psicoativa ou, ainda, sob dependência de droga (artigos 26 e 28 do Código Penal e do artigo 45 da Lei 11.343/2006).

Por fim, culturalmente inseridos na sociedade brasileira, os réus tinham ao menos potencial consciência da ilicitude e não há elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que lhes fosse inexigível conduta diversa, por estar sob coação irresistível ou agir em estrita obediência a ordem (artigo 22 do Código Penal).

Dosimetria

Passo à individualização da sanção penal exigida pelo artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, no procedimento trifásico do artigo 68, caput, do Código Penal, na medida em que necessária e suficiente à retribuição e à prevenção especial.

Na primeira etapa (artigo 59, incisos I e II, do Código Penal), aprecio as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis a partir da pena média, a fim de atender o princípio da isonomia do artigo 5º, caput, da Constituição Federal, pois “é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador. Esse é um ponto estratégico na individualização da pena, justamente para evitar a nociva padronização. A quem merece pena superior ao mínimo, deve o juiz saber aplicá-la, por uma questão de justiça.” (Guilherme de Souza Nucci, Curso de Direito Penal, v. 1, 3ª ed., 2019, Cap. XXXII, item 3.1, p. 1020). Do contrário, dar-se-ia idêntico tratamento para condutas de distinta reprovabilidade quando presentes exclusivamente circunstâncias judiciais favoráveis.

O nível de consciência do injusto e o grau de exigibilidade de comportamento diverso (cf. Juarez Cirino dos Santos, Direito Penal – Parte Geral, 5ª ed., 2012, p. 518-519) não destoam da culpabilidade já pressuposta na caracterização do crime. O acusado MARCOS não ostenta Maus antecedentes, inexistindo condenação criminal transitada em julgado a ser valorada nesta fase, conforme exige a presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), nos moldes da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça e da tese com repercussão geral decidida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 591054, Relator(a): Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2014).

Contudo, a condenação já referida de GABRIELLY deve ser negativamente valorada a título de Maus antecedentes, diante da natureza do crime antes cometido e do tempo decorrido desde então, de pouco mais de 5 anos.

Nada de desfavorável se comprovou a respeito da conduta social dos acusados, o que, de qualquer modo, só justificaria sanção penal mais gravosa em função da prevenção especial positiva, prejudicada ante o “quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas” no sistema penitenciário brasileiro (STF, ADPF 347 MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015). Não tendo o titular da ação penal, neste ponto, se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, de rigor considerar favorável a conduta social dos acusados, em atenção ao in dubio pro reo (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

Não há elemento probatório seguro a respeito da personalidade dos acusados, o que é questão técnica complexa e de, no mínimo, duvidosa convencionalidade (v. Corte Interamericana de Direitos Humanos, Fermín Ramírez vs. Guatemala, julgado em 20/06/2005).

Os motivos e as circunstâncias do crime não destoam do que é acobertado pelo tipo penal e não justificam imposição de sanção mais branda ou mais severa.

As consequências do crime são igualmente neutras, nesta fase, diante da extensão relevante, mas não excessiva, de atingimento ao bem jurídico tutelado.

O comportamento da vítima não contribuiu para o delito, cuja censurabilidade não é por isto diminuída.

Por tudo isto, desfavoráveis os Maus antecedentes de GABRIELLY e, para ambos, favorável a conduta social e neutras as demais circunstâncias. Não havendo motivo para atribuição de sobrevalor a nenhuma delas, atribuo a cada circunstância favorável e desfavorável peso equivalente a 1/6 sobre o intervalo de pena em abstrato. A fração é eleita em interpretação sistemática da fração mínima das causas de aumento e diminuição expressas no Código Penal, aplicando-se sobre o

intervalo em respeito ao papel do legislador na individualização da pena, de modo que possa alcançar o piso ou o teto legais.

Fixo a pena-base em 6 anos de reclusão (MARCOS) e em 7 anos de reclusão (GABRIELLY).

Na segunda etapa (artigos 61 a 67 do Código Penal), é de rigor a atenuação da pena de MARCOS em razão da menoridade e da confissão (artigo 65, incisos I e III, 'd', do Código Penal), ainda que qualificada (cf. STJ, AgRg no AREsp 1763911/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/06/2021, DJe 24/06/2021; AgRg no AREsp 1754440/MT, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021), pois prepondera, aqui, a colaboração com a apuração criminal e a certeza do julgamento em detrimento do arrependimento e penitência pelo crime; e seu agravamento por força do artigo 61, inciso II, alínea 'h', do Código Penal.

Para GABRIELLY, não há atenuantes a considerar diante de sua idade e da negativa de qualquer envolvimento no crime.

Por conseguinte, observada a preponderância dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência, atenuo a pena de MARCOS em 3/12 sobre o intervalo de pena em abstrato e agravo a pena de GABRIELLY em 1/6 sobre o intervalo de pena em abstrato, passando a pena intermediária a 4 anos e 6 meses (MARCOS) e a 8 anos (GABRIELLY).

Por fim, na terceira etapa, elevo a pena de 2/3 de acordo com o artigo 157, parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, deixando de valorar as demais causas de aumento da parte especial, na forma do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal e da Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, pois já desnecessárias para a retribuição e prevenção especial diante do caso concreto.

De rigor a redução da pena de GABRIELLY em 1/3 diante do grau de reduzida importância de sua participação (artigo 29, parágrafo 1º, do Código Penal).

Na forma do artigo 29, parágrafo 2º, parte final, do Código Penal, a pena deve ser elevada ainda de 1/6, em razão da previsibilidade do resultado mais gravoso, mas considerando que a morte das vítimas acabou não se consumando.

Assim, fixo a pena privativa de liberdade em 8 anos e 9 meses de reclusão (MARCOS) e 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão (GABRIELLY).

Quanto à pena pecuniária, a gradação do número de dias-multa deve observar rigorosamente o sistema trifásico do artigo 68 do Código Penal, conforme tudo o que já se expôs, apenas com a ressalva de que o intervalo do artigo 49 do Código Penal, de 10 a 360 dias-multa, deve ser proporcional, pelo imperativo constitucional da isonomia, à natureza e à gravidade do delito (v. Cezar Roberto Bitencourt, Tratado de Direito Penal, v. 1, Saraiva, 2009, p. 613). Para tanto, adota-se como teto da primeira fase valor proporcional à pena máxima cominada para o delito em comparação com o máximo de 30 anos cominado pelo Código Penal.

Assim, correspondendo a pena de multa máxima proporcional a 126 dias-multa e a pena-base a 49 dias-multa (MARCOS) e a 68 dias-multa (GABRIELLY), fixo a pena de multa final em 70 dias-multa (MARCOS) e em 112 dias-multa (GABRIELLY).

Ausentes elementos sobre a condição econômica dos acusados, fixo o valor do dia-multa, nos moldes do art. 49, § 1º, do CP, em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

Regime inicial

Deixo de promover a detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, remetendo a questão ao juízo da execução. Com efeito, o preceito incluído pela Lei 12.736/12 confunde os institutos diversos da fixação do regime inicial e da progressão de regime e, deste modo, viola a Constituição Federal, que consagra a individualização da pena e a isonomia (artigo 5º, caput e incisos I e XLVI).

Em razão da condenação a pena de reclusão superior a 8 anos, fixo o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea 'a', do Código Penal.

Substituição e sursis

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante da quantidade de pena aplicada por crime doloso, não preenchido o requisito do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Também não cabe a suspensão condicional da pena, fixada em mais de 4 anos, assim independentemente da idade dos acusados ou de razões de saúde (artigo 77, caput e parágrafo 2º, do Código Penal).

Indenização mínima

Deixo de fixar a indenização mínima (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal) à míngua de pedido do Ministério Público ou da vítima, em homenagem ao princípio do contraditório.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão acusatória para condenar MARCOS HENRIQUE GUIMARÃES CARVALHO à pena de reclusão de 8 anos e 9 meses, em regime inicial fechado, e a 70 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, pela prática do crime do artigo 157, caput, com as causas de aumento dos parágrafos 2º, inciso I e 2º-A, inciso I, daquele dispositivo, combinado com o artigo 29, parágrafo 2º, todos do Código Penal; e condenar GABRIELLY DA SILVA à pena de reclusão de 10 anos, 4 meses e 13 dias, em regime inicial fechado, e a 112 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, pela prática do crime do artigo 157, caput, com as causas de aumento dos parágrafos 2º, inciso I e 2º-A, inciso I, daquele dispositivo, combinado com o artigo 29, parágrafos 1º e 2º, todos do Código Penal.

Prisão preventiva

Nos termos do artigo 387, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, aprecio e mantenho a prisão preventiva. Mantida a prisão durante a instrução criminal, porque presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo imprescindível à preservação da ordem pública e à aplicação da lei penal, e ora confirmada, com a condenação, a imputação por crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tais requisitos subsistem de forma ainda mais nítida.

Assim, recomendo os acusados à prisão. Expeça-se a guia de recolhimento provisória (artigo 8º da Resolução CNJ 113/2010).

Custas

Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno os réus ao pagamento das custas processuais (artigo 4º, parágrafo 9º, alínea 'a', da Lei Estadual 11.608/03). A gratuidade é questão a ser apreciada em momento oportuno, pelo juízo da execução, se o caso.

Providências Finais

Comunique-se à vítima (artigo 201, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal).

Com o trânsito em julgado, expeça-se a guia de recolhimento definitiva, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Penal e da Resolução CNJ 113/2010; comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal; e comunique-se ao Instituto de Identificação Civil (artigo 709 do Código de Processo Penal).

Também após o trânsito em julgado, atualize-se o histórico das partes no cadastro processual com a respectiva anotação; expeça-se a certidão de honorários ao advogado dativo, se o caso; expeça-se a competente certidão para execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa).

Comunicado o ajuizamento da execução da multa (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou verificada a prescrição da pretensão executória (evento 22), arquivem-se os autos com a movimentação 61619 no SAJ.

Int.

Mongaguá, 19 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA